

1516870-75.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... penal.

"Agravamento regimental no habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Inquéritos e ações penais em curso. Utilização para afastamento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Novel entendimento da primeira e segunda turmas do STF. Natureza e quantidade da droga apreendida. Art. 42 da lei n. 11.343/2006. Circunstância preponderante a ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1516870-75.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

EVELYN MARCELA VENTURA VITAL DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data de 26 de julho de 2022, às 14:20h, no Bairro de Ermelino Matarazzo, mais especificadamente na Rua Tomé Braga, altura do nº 318, nesta capital, transportou para fins de mercancia de ilícitos, dois "tijolos" de cocaína em forma de crack pesando 1.973,3g.

Presa em flagrante, manteve-se detida até a audiência de instrução, debates e julgamento, vez que a prisão pré-cautelar foi convertida em preventiva após audiência de custódia (fls. 44/48).

Deferido o processamento da denúncia (fls. 70/72), foi o réu notificado (fl. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 98/99).

Recebida definitivamente a denúncia (fls. 106/107), nesta data foram ouvidas duas testemunhas e a acusada, por fim, foi interrogada.

Em debates, a Promotoria de Justiça postulou pela procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e deduziu pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia deve ser julgada procedente.

Interrogada em Juízo, a acusada confirmou a prática.

Embora a confissão não seja considerada a "rainha de todas as provas", note-se que a admissão da ré encontra respaldo no contexto probatório.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 04), no boletim de ocorrência (fls. 05/08), no auto de apreensão e exibição (fl. 17), bem como nos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 26/29), sendo certa a autoria.

Os policiais militares ouvidos em sede policial e em Juízo, Guilherme e Cristiane, prestaram versão uníssona, crível e verossímil, a qual encontrou eco em toda a prova constante nos autos. Em suas palavras, disseram que na data dos fatos realizavam patrulhamento em via pública, quando avistaram a ré saindo de um bar, enquanto portava uma bolsa de alça de cor rosa. A bolsa estava deformada, o que levantou a suspeita dos agentes. Após visualizar a viatura, a acusada mudou de direção e começou a correr, o que chamou definitivamente a atenção dos agentes. Após breve perseguição conseguiram deter a imputada, tendo encontrado com ela um celular, R\$ 52,00 e dois "tijolos" do que aparentava ser crack. Informam que a ré transportava a droga para "ganhar uma grana", sem, contudo, informar de onde e para onde levava os entorpecentes.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, não há prova de que tais policiais tivesse interesse o menor interesse em prejudicar a ré. Em nada aproveitaria aos policiais a prisão supostamente ilegal.

Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento com espreque tão somente na respectiva condição funcional, vez que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dá conta das suas atividades.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando, não somente a quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida, mas também sua forma de acondicionamento, típicas da atividade de tráfico.

Embora não tenha sido encontrada multiplicidade de substâncias ilícitas, é inegável que a quantidade encontrada não é pequena (quase dois quilos) o que afasta qualquer alegação de uso. Ademais, devido ao potencial destrutivo/viciante do crack seria impossível uma única pessoa consumir tudo isto em curto espaço de tempo.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de transporte de entorpecentes, o que se encaixa perfeitamente com a descrição típico-normativa constante no art. 33 da lei 11.343/06. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou mesmo à desclassificação.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco anos) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, calculados estes no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mesmo reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos fatos, deve a pena ser mantida em seu mínimo legal. Como bem se sabe e há muito decidido, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 231), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo estabelecido pelo legislador.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento de pena, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento: não primariedade, ausência de bons antecedentes, dedicação a atividades criminosas e participação em associações criminosas. Resta agora, porém, discorrer acerca do percentual de redução. Neste passo, tenho por mais acertada a lição doutrinária contida na obra acima referida que preconiza a aplicação da regra do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, o qual determina que na fixação das penas, serão considerados, com preponderância, os critérios do artigo 59 do Código Penal, juntamente com a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

Neste sentido, aliás, encontramos abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput da lei 11.343/06). Pena fixada em 5 anos de reclusão. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º. Do art. 33 da lei 11.343/06 na proporção de 1/3. Pena concretizada: 3 anos e 4 meses de reclusão. Ausência de motivação. Exame favorável de todas as circunstâncias judiciais. Agente primário e possuidor de bons antecedentes. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer ministerial pelo deferimento do writ. 1. Se o legislador da lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do cpb, como as demais mencionadas na lei antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas. 2. (...). 3. (...). 4. (...).” (hc 120.832/rs, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julg. 04/06/2009, dje 03/08/2009).

Saliente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo a tese de

que a causa de diminuição de pena em questão não pode ser afastada pelo simples fato de que o acusado é investigado em inquérito ou réu em outra ação penal.

“Agravos regimentais no habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Inquéritos e ações penais em curso. Utilização para afastamento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Novel entendimento da primeira e segunda turmas do STF. Natureza e quantidade da droga apreendida. Art. 42 da lei n. 11.343/2006. Circunstância preponderante a ser necessariamente observada na primeira fase da dosimetria. Utilização para afastamento do tráfico privilegiado ou modulação da fração de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. Caracterização de bis in idem. Não tolerância na ordem constitucional. Agravo regimental desprovido. (...) 8, Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). (AgRg no HC 676.516/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, reduzo a pena em 1/2 (metade), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada, enfatizando a qualidade da droga apreendida, cocaína, de grande potencial, além da quantidade de entorpecente, quase dois quilos. Como consequência, a pena restará definida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao regime prisional impositivo à espécie, mister fixar-se a modalidade inicial semiaberta, por ser socialmente recomendável, diante das circunstâncias fáticas do caso, principalmente por envolver apreensão de grande quantidade de crack, droga esta de imensa potencialidade lesiva e viciante.

Por fim, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a lesividade que tal entorpecentes contém, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada e suficiente, razão pela qual deixo de operar a referida substituição.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a acusada EVELYN MARCELA VENTURA VITAL DA SILVA como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Tendo a ré permanecido presa ao longo do processo, assim permanecerá em caso de recurso, vez que ainda presentes os motivos pelos quais se decretou a medida cautelar, notadamente agora que condenada.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Por fim, determino de incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento da quantia em dinheiro, fruto de atividade ilícita. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA